

1500742-48.2021.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... acusado transportava drogas destinadas ao tráfico. A respeito dos fatos, os policiais esclareceram que, durante patrulhamento de rotina, perceberam o acusado caminhando na via pública, conhecida por ser local de intensa pratica de trafico de drogas.

Com efeito, analisando as condições da atuação policial, vislumbro fundada razão para a abordagem, decorrente da postura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500742-48.2021.8.26.0637 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500742-48.2021.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2160694/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 18493444 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 1463/21/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2160694 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2160694 - 03º D.P. TUPÃ, 1463/21/229 - 03º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS FAGUNDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR

Vistos.

JONAS FAGUNDES, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia de fl. 171/175, no dia 14 de junho de 2021, às16h40, na Rua Piratininga, nº 203, Vila das Indústrias, nesta cidade e Comarca de Tupã, transportava e trazia consigo, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros, 30 porções de cocaína, com peso liquido de 3,82 gramas (peso bruto11,76 g), e 02 porções de "maconha" - TETRAHIDROCANNABINOL (THC), com peso liquido de 49,66 gramas (peso bruto 55,58 g), - cf. auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação de fls. 12/14 e 17/19; sem autorização

e em desacordo com determinação legal e regulamentar. As referidas substâncias causam dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

O réu foi notificado (fl. 216) e apresentou defesa preliminar às fls. 220/221, não evitando, contudo, o recebimento da denúncia (fls. 222/224).

Durante a instrução processual foram ouvidas 03 testemunhas em comum, e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 259/261; 262 – mídia portal Esaj). Foi instaurado incidência de insanidade mental/dependência toxicológica nos autos nº 0004138-10.2021.8.26.0637, e o laudo pericial acostado a fl. 56/59, o qual certifica a imputabilidade do acusado.

Em alegações finais escritas, o Ministério Público, fls. 306/313, reiterou o pleito condenatório reiterando o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do acusado.

Em alegações finais escritas, fls. 316/326, a Defensoria Pública, por seu turno, suscitou que não há provas suficientes para a condenação. Postulou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da 11343/06. Em caso de condenação, requereu a aplicação de regime inicial mais brando, e recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pese a combatividade da defesa, a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público comporta acolhimento.

No cerne da imputação, a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente provadas nos autos, de acordo com o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, fotografias dos estupefacientes, laudos periciais, relatório final do Delegado de Polícia, bem como pelas provas orais produzidas em solo policial e ratificadas em audiência, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

A testemunha KARINA RIBEIRO DE SOUZA, em juízo afirmou que, na data dos fatos, foi até a casa de sua cunhada, e quando estava no portão para entrar na residência, o réu apareceu. Disse que, então, fez sinal para sua cunhada não abrir o portão, tendo o portão ficado “meio aberto”, momento em que passou os policiais. Afirmando que então o acusado passou a falar coisas desconexas, como “deixar o currículo”, quando passou dois policiais de moto, e conseguiu dar sinal para os policiais. Asseverou que os policiais retornaram e abordou o acusado, momento em que ele entrou em desespero e tentou entrar na casa de sua cunhada. Relatou que então os dois policiais ficaram do lado de fora do imóvel, puxando o acusado, e ela e sua cunhada do lado de dentro da casa tentando fechar o portão, porque o acusado ficou “preso” no portão, tentando entrar. Informou que então os policiais conseguiram conter o acusado.

A testemunha LUIS CARLOS RONCADA DE OLIVEIRA, ouvido em juízo afirmou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando o acusado, ao avistar a presença das motocicletas da ROCAM, mudou seu trajeto e foi até uma residência iniciando conversa com uma senhora, a qual se espantou com a presença dele, e por isso retornou e realizou a abordagem. Esclareceu que ao fazer a abordagem o réu tentava ingressar na residência da referida senhora. Disse que conseguiram conter o acusado, e em revista pessoal, no bolso direito, encontraram duas porções grandes de maconha e 30 porções de cocaína,

bem como a quantia de R\$ 10,00 (dez reais).

A testemunha JOSE ANTONIO MARIOTTI DE SOUZA, ouvido em juízo, confirmou os fatos narrados por seu colega de trabalho. Narrou que estava em patrulhamento de rotina com motocicleta e observaram JONAS caminhando pela rua, e ao avistar a aproximação dos policiais, se aproximou de uma moça que estava adentrando em uma residência. Informou que então retornaram e ao tentar abordar o acusado, ele tentou entrar na residência, que conseguiu fechar o portão. Mencionou que houve resistência do acusado, mas lograram êxito em detê-lo, e que em revista pessoal encontraram duas porções grandes de maconha e 30 porções de crack.

O réu JONAS FAGUNDES, interrogado em juízo, negou a prática delitiva. Afirmou que é usuário de entorpecentes, e que nunca precisou vender droga para sobreviver. Disse que, na data dos fatos, foi na casa de sua irmã para conversar com ela. Negou que estava com drogas quando foi abordado pelos policiais, e que somente estava com um baseado e com a nota de R\$ 10,00.

Pois bem; em que pese a argumentação defensiva, indiscutível que o acervo probatório permite a conclusão, de forma indene de dúvidas, de que o acusado transportava drogas destinadas ao tráfico. A respeito dos fatos, os policiais esclareceram que, durante patrulhamento de rotina, perceberam o acusado caminhando na via pública, conhecida por ser local de intensa prática de tráfico de drogas. Com efeito, analisando as condições da atuação policial, vislumbro fundada razão para a abordagem, decorrente da postura evasiva por parte do acusado em local de extensa prática de tráfico de entorpecentes, sendo legítima, fundada e legal a atuação policial.

Em que pese a negativa do acusado, esta, quando confrontada com as demais provas produzidas, mostra-se frágil, vacilante e detentora de reduzido poder de convencimento.

Quanto à seriedade da versão policial, é digno de nota que o art. 202 do Código de Processo Penal possui a categórica redação de que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Significa dizer que, ressalvado o disposto no art. 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo prestar o compromisso legal. De outro vértice, incumbe ao Magistrado, na forma do art. 155 da Lei Adjetiva, avaliar todas as provas amealhadas e, uma vez formada sua convicção, proceder à exposição dos fundamentos conforme o art. 93, inciso IX, da Magna Carta. Em suma, este Juízo colhe a prova oral e analisa concretamente com os demais elementos dos autos, sem quaisquer presunções prévias positivas ou negativas.

Dessume-se facilmente deste caderno processual que os depoimentos policiais são harmônicos, firmes e coesos, encontrando amparo nos demais substratos de prova (notadamente o boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudos periciais, etc). Comungo do mesmo posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que pacificou que “não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha” - RHC 108586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/08/2011. Em idêntico sentir, invoco: “(...) Fundamentação da sentença: valoração da prova com prestígio aos testemunhos dos policiais, fornecendo subsídios que convenceram o magistrado acerca da versão contida na denúncia. (...) Inocorrência de nulidade da sentença, eis que foi cumprida rigorosamente a noção de correlação entre acusação e sentença. Observância do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)” - excerto da ementa do HC 91883, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., j. 24/06/2008.

Em vetusta decisão da Suprema Corte, colige-se o posicionamento pacífico de que: “PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no

fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido" - HC 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, julgado em 04/08/1998.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido iterativamente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto "(...) a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (...)" - HC 477.171/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 22/11/2018.

Em idêntico sentir, "(...) não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado (...). É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ (...)" - HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/06/2017.

Não bastasse o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores, inexistente lógica no aparato do Estado: (I) realizar concurso público para as carreiras policiais; (II) selecionar os indivíduos com a melhor classificação nas avaliações teóricas, práticas e psicotécnicas; (III) submetê-los a treinamento intenso nas Academias; e (IV) conferir-lhes o monopólio do uso da força para prevenir, combater e investigar a prática de crimes - inclusive com autorização de porte de arma de fogo e materiais bélicos - e, de forma contraditória, simplesmente desconsiderar as suas palavras quando são chamados a depor na fase inquisitiva e em Juízo. Aliás, consoante as ponderações do Excelentíssimo Desembargador Alcides Malossi Junior (excerto do voto da Apelação 1500527-90.2018.8.26.0471, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgada em 24 de junho de 2020, sem grifos originais):

"não há como se alegar que as palavras de funcionários públicos, diretamente envolvidos no evento, não mereçam credibilidade, porquanto foram sérias e harmônicas, não havendo nos autos qualquer elemento a demonstrar que estivesse ele a mentir, para imputar um delito a pessoa que soubessem ser inocente. A presunção juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de agentes policiais quanto aos atos de diligência e apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de poder deles, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se alegou e se comprovou a respeito. Ademais, seria um contrassenso o Estado lhes dar crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestar contas de suas atividades". Pontue-se ainda que os substratos probatórios colhidos na fase policial, quando referendados judicialmente, podem sedimentar o édito penal condenatório, conforme resta pacificado na Suprema Corte, pois a "condenação lastreada em provas obtidas na fase inquisitorial e posteriormente submetidas ao crivo do contraditório, justificando a condenação do réu e afastando a hipótese de nulidade do processo. Embora vedado o revolvimento probatório na estreita via do habeas corpus, seria possível reconhecer, no bojo do writ, uma eventual ocorrência de nulidade. Não é, contudo, o caso dos autos, em que o julgamento está lastreado em acervo probatório fartamente indicado na decisão atacada (...)" - HC 93627, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª T., DJe 05/02/2009.

De mais a mais, “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo' (...). Dessa feita, os depoimentos prestados por réus e testemunhas na fase policial, na parte em que harmônicos com a prova documental e com a prova oral colhida em juízo, podem servir para a formação do convencimento judicial quanto à responsabilidade penal do agente” - AP 618/RJ Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 13/12/2016.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido na mesma singra: “(...) A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 10/9/2019) (...)” - excerto do AgRg nos EDcl no AREsp 1585359/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 03/06/2020.

A título de registro, em que pese as versões do réu, afirmando que os policiais tentando desqualificar a manifestação dos milicianos, observa-se que suas palavras são pouco críveis e que não há qualquer indício que os gendarmes tenham confabulado para incriminá-lo.

No mérito da imputação, cumpre destacar que este Magistrado compreende que o art. 28, §2º, da Lei de Drogas, interpretado a contrario sensu, permite a análise casuística para se aferir se os entorpecentes são destinadas a consumo próprio ou ao tráfico. Referido posicionamento também foi sufragado na Apelação 0045618-90.2015.8.26.0050, Rel. Des. Grassi Neto, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. 28/06/2018. Ainda na seara exegética, também é aplicável o art. 51, inciso I, do mesmo diploma legal, para permitir o balizamento da situação fática perante a tipicidade em abstrato do delito de tráfico de drogas.

Segundo as diretrizes dos preceptivos em comento, analisando a natureza (cocaína e maconha) e sua diversidade, o local e às condições em que se desenvolveu a ação (abordagem em via pública conhecida pela prática de tráfico de entorpecentes), as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes o agente (maus antecedentes e reincidente), indiscutível que as drogas eram destinadas a terceiros, e não ao consumo próprio. Assim, não há que se cogitar em absolvição. O Egrégio Colegiado Bandeirante tem decidido, de forma assente e pacífica, que são as especificidades do caso concreto (quantidade e variedade das substâncias apreendidas, local dos fatos, desenvolvimento da conduta, antecedentes policiais/criminais do acusado, dentre outros dados empíricos) que permitem a análise e a conclusão da subsunção do fato ao art. 33 da Lei de Drogas, ou a eventual possibilidade de desclassificação para o delito do art. 28 do mesmo diploma. Em abono, vide precedentes: Apelação 0002856-33.2016.8.26.0597, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, 10ª Câmara de Direito Criminal, r. 12/05/2020; Apelação 1500370-44.2019.8.26.0484, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara de Direito Criminal, r. 12/05/2020; Apelação 1540082-77.2018.8.26.0451, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, 2ª Câmara de Direito Criminal, r. 11/05/2020.

Cumprir registrar que, para a caracterização do delito em tela, não se exige a finalidade lucrativa, tampouco que ao agente tenha praticado a conduta de venda e/ou entrega de estupefaciente a usuários. Invoco ainda o abalizado escólio de RENATO BRASILEIRO DE LIMA (Legislação Criminal Especial Comentada, Volume Único, Editora Juspodium, 5ª edição, p. 1.007/1.012, sem destaques originais) que, em explanação quanto aos DEZITO verbos e à tipicidade do crime do art. 33 da Lei de Drogas, leciona o seguinte:

“Todas as condutas acima mencionadas têm o complemento ainda que gratuitamente, ou seja, sem cobrança de qualquer preço ou valor. Portanto, é de todo irrelevante haver ou não lucro, ou mesmo intuito de lucro. Os vários núcleos verbais constante do art. 33 da Lei de Drogas fazem dele um crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Assim, mesmo que o agente pratique, em um mesmo contexto fático, mais de uma ação típica, responderá por crime único, haja vista o princípio da alternatividade (...). Apesar de a expressão 'tráfico de drogas' estar relacionada à ideia de mercancia e lucro, fato é que para a tipificação desse crime dispensa

qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de praticar um dos 18 (dezoito) verbos constantes do art. 33. Portanto, diversamente do crime do art. 28 da Lei de Drogas, que se caracteriza pela presença do especial fim de agir de o agente trazer a droga consigo para consumo pessoal, sendo considerado, pois, tipo incongruente (ou congruente assimétrico), os crimes de tráfico de drogas são espécies de tipos congruentes, vez que há perfeita adequação entre os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, isto é, são infrações desprovidas de qualquer outro elemento subjetivo – o chamado dolo específico da doutrina tradicional (ou o especial fim de agir)".

No mesmo sentir, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA INTENÇÃO DE TRAFICAR 329G (TREZENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS) DE MACONHA APREENDIDOS COM O AGRAVANTE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA PRÁTICA DE UMA DAS DEZOITO CONDUTAS RELACIONADAS A DROGAS PARA QUE HAJA A CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO PENAL. 1. "O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido - AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 28/08/2019.

Considerando o posicionamento da doutrina e da jurisprudência, forçoso concluir que a tipicidade do crime de tráfico é extraída das circunstâncias do caso concreto, em cotejo com todo o mosaico probatório. No caso em tela, a apreensão das drogas, em razoável quantidade, em local de intensa prática do delito de tráfico de drogas, permitem concluir, de forma indene de dúvidas, que a conduta amolda-se ao art. 33 da Lei de Drogas.

Conforme já mencionado adrede, o caput do art. 33 da Lei de Drogas estampa dezoito verbos e, em se tratando de tipo misto alternativo, basta a prática de uma das condutas para a configuração do crime. Demais disso, para a tipicidade, não se exige nenhum elemento subjetivo ou normativo adicional, tampouco o desiderato especial do agente.

No mesmo sentir, já decidiu o Egrégio Colegiado Bandeirante:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Apelante preso em flagrante delito trazendo consigo 8 porções de cocaína (11g) e guardando 14 porções de maconha (22,6g), bem como R\$ 35,00 em dinheiro trocado. Policiais militares que confirmaram a apreensão do entorpecente em um embrulho que acusado trazia consigo e "dispensou" ao vê-los, bem como em local escondido indicado pelo réu. Acusado que negou a traficância em solo policial, mas acabou confessando em Juízo, afirmando que o fez para pagar uma dívida com traficantes. Confissão judicial em consonância com o contexto probatório. Desnecessária prova da efetiva comercialização, porquanto as condutas de guardar e trazer consigo (para entrega a terceiros) já se sobsomem ao tipo penal. Condenação pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 mantida. PENAS. Base fixada no mínimo legal, compensadas a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, negado o redutor, em se cuidando de reincidente. Pena definitiva de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa mínimos. Manutenção. REGIME PRISIONAL. Manutenção do regime inicial fechado, ante a reincidência do réu, aliada à pena corporal aplicada, superior a quatro anos e em se cuidando do único cabível ante a gravidade concreta do delito praticado, evidenciada nocividade de boa parte do entorpecente apreendido, com vistas principalmente à prevenção delitiva e à tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade. BENEFÍCIOS LEGAIS. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal, ante a pena concretizada e a reincidência, a par da gravidade concreta do crime em julgamento e a absoluta incompatibilidade de tais benesses com o regime de pena cabível. Recurso defensivo desprovido. Apelação 1500993-83.2019.8.26.0072,

Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, r. 28/05/2020.

TRÁFICO. Configuração. Conduta de guardar, para fins de tráfico, mais de 1,5kg de cocaína. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante confirmada em Juízo. Confissão espontânea de um dos apelantes. Alegação de que os entorpecentes foram guardados por conta de dívida de drogas. Argumento que não pode ser considerado caracterizador de coação moral irresistível. Condenação mantida. Penas reduzidas. Aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas apenas para um dos apelantes, em seu grau mínimo. Manutenção do regime fechado para ambos. Impossibilidade do afastamento da pena de multa. Alegada hipossuficiência que deverá ser analisada em sede de Execução Penal. Apelo parcialmente provido. Apelação 0073535-89.2012.8.26.0050, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16ª Câmara de Direito Criminal, r. 18/02/2014.

Com relação à CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA estampada no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, destaco a impossibilidade de aplicação na situação em comento, considerando que foram apreendidos entorpecentes quantidade razoável para os padrões regionais do Município de Tupã – bem como pela reincidência certificada do acusado, por expressa vedação legal.

É certo que a legislação estabelece pressupostos obrigatoriamente indissociáveis. Conforme preconizado pela jurisprudência superior, “para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é necessário o preenchimento dos quatro requisitos cumulativos (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa). A ausência de qualquer um deles impede a concessão do benefício” - AgRg no REsp 1449194/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T. do C. STJ, DJe 04/10/2017. A respeito, a Suprema Corte tem decidido que: “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores do envolvimento do agente com organização criminosa, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação dos pacientes a atividades criminosas, sobretudo em razão da quantidade de droga apreendida” - HC 143577 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª T., j. em 16/10/2017; “PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Possível é levar-se em conta, para efeito do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade de entorpecentes” - HC 133157, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 08/08/2017.

Destarte, como não foram satisfeitos os pressupostos legais, inexistente margem à concessão de referido benefício.

Reputo que há prova segura da existência de fatos típico, antijurídico e culpável; assim, plenamente convicto pela condenação, por infração ao art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006, passo à DOSIMETRIA DA PENA, concorde ao critério trifásico do art. 68 do Estatuto Repressor:

Na primeira fase da dosagem, atento ao art. 42 da Lei Federal 11.343/2006, verifico que a natureza da droga encontrada com o sentenciado, qual seja, cocaína, é extremamente nociva à saúde pública, bem como detém alto poder destrutivo, causando assim um considerável grau de dependência. O Colendo Tribunal da Cidadania sedimentou o entendimento de que o crack e a cocaína justificam o incremento da sanção pela nocividade destas drogas. A respeito, vide os precedentes: AgRg no HC 476.995/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T. DJe 03/05/2019; HC 404.692/PB, Rel. Min. Félix Fischer, 5ª T., DJe 08/05/2018; HC 306.565/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T. STJ, DJe 07/05/2015; HC 186.626/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 23/04/2012.

No tocante ao art. 59 do Código Penal, atento à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e

consequências do crime. Logo, diante de sobredito panorama, considerando a quantidade, natureza e nocividade da droga apreendida, bem como pela existência de MAUS ANTECEDENTES, exaspero a pena-base em 1/4 (um quarto), fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de Reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Já na segunda etapa da dosimetria, não verifico a existência de circunstâncias atenuantes genéricas (art. 65 do Código Penal). De outro vértice, reconheço a REINCIDÊNCIA. Logo, incremento a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 7 (sete) anos, 3(três) meses e 15(quinze) dias de Reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Por fim, no terceiro estágio do procedimento dosimétrico, não observo quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena previstas no Código Penal ou na Legislação Especial. Não há que se falar na incidência do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, tendo em vista que, conforme já salientado alhures, ostenta maus antecedentes e recidiva. Logo, diante desse panorama, fixo a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 3(três) meses e 15(quinze) dias de Reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

- PÓS-DOSIMETRIA

Ausentes provas concretas acerca das condições financeiras e econômicas dos condenados, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, de acordo com o art. 43 da Lei Federal 11.343/2006 c/c o art. 49, § 1º, Código Penal, pois inexistem elementos para estabelecer a reprimenda pecuniária acima do piso expresso na legislação especial e no Diploma Geral.

Pela expressa previsão dos arts. 44 e 77 e incisos, ambos do Código Penal, verificando o quantum de pena aplicado (superior a quatro anos) e a reincidência, deixo de proceder à substituição da sanção corporal pelas penas restritivas de direito.

Tendo em vista que a condição de reincidente do acusado, faz-se necessária a fixação do regime inicial de cumprimento de pena FECHADO, ante a gravidade concreta do delito e acentuada periculosidade do réu, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Reputo que é invável o abrandamento prisional pelo disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, na medida em que a fixação do regime inicial do cumprimento de pena não decorreu, exclusivamente, da quantidade de reprimenda. Com efeito, conforme argumentado alhures, este Juízo analisou as circunstâncias do presente caso, tais como a quantidade e nocividade da droga, reincidência, maus antecedentes, periculosidade do agente, dentre outros vetores. Não se trata, portanto, de simples critério matemático de adequação, mas de exame percuciente de aspectos fático-jurídicos que influem na convicção do Julgador.

Conforme tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "(...) embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a circunstância judicial desfavorável (quantidade da droga) justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP)" -AgRg no REsp 1846545/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 27/02/2020.

De mais a mais, apesar de entendimentos em sentido diverso, este Magistrado tem interpretado o preceptivo em voga como uma progressão de regime anômala, e não mera detração. Logo, a aferição dos requisitos subjetivos e objetivos, para a alteração de sistema de cumprimento de pena, deve ser feito com acuidade pelo Douto Juízo da Execução, que reúne os meios e condições para exame da situação do réu.

Em caso análogo, vide o precedente do Superior Tribunal de Justiça: "(...) ocorre que, mesmo não se confundindo a detração penal com a progressão de regime, é consolidado o entendimento desta Corte Superior de que se estiverem ausentes, nos autos, os elementos necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2º, do CPP, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar do envolvido autoriza a fixação de regime mais brando, como no presente caso. Agravo regimental desprovido" - AgRg no REsp 1838031/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 19/12/2019.

- EM ARREIMATE, atento ao disposto nos INCISOS DO §2º DO ART. 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019), cumpre destacar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não são capazes, ao menos em tese, de infirmar a conclusão adotada por este Magistrado - uma vez que houve exaustiva análise de todas as proposições fáticas e jurídicas suscitadas pela acusação e defesa.

Conforme já decidido pelo Excelso Pretório quanto à fundamentação, certo que “não há divergência entre o que decidido pelo Tribunal a quo e o entendimento do Supremo Tribunal segundo o qual 'o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento' (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008) (...)” - AI 742202 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 06/04/2010. Além disso, “(...) prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que 'o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte' (AgRg no AREsp n. 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017) (...)” - excerto da ementa do AgRg no HC 466.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça, DJe 10/05/2019.

Também é digno de nota que o mesmo Sodalício, em exame do art. 489 do Código de Processo Civil (cuja redação é idêntica ao do preceptivo introduzido no Código de Processo Penal pelo projeto chamado de “Pacote Anticrime”), firmou o posicionamento que “(...) conforme entendimento pacífico desta Corte: 'O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016) (...)” - excerto da ementa do RESp 1832993/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T. STJ, DJe 13/12/2019.

- DISPOSITIVO

1) Ante todo o exposto na fundamentação e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para:

I) CONDENAR o acusado JONAS FAGUNDES, qualificado nos autos, como incurso na descrição típica prevista no art. 33, caput, da Lei Federal 11.343/2006 (Lei de Drogas), ao cumprimento da pena privativa de liberdade correspondente a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em seu parâmetro mínimo legal.

2) Nos termos do §1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, vislumbrando a demonstração de circunstâncias cautelares concretas, ante a ausência de modificação do quadro probatório que motivou a decretação e manutenção da prisão preventiva (fls. 91/94 e 133/134), bem como pelo quantum de pena aplicado e o regime inicial do cumprimento da sanção corporal e sua espécie (RECLUSÃO no FECHADO), NEGO ao réu o direito de recorrer da presente decisão em liberdade.

De mais a mais, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que não há lógica em deferir a liberdade provisória ao sentenciado que respondeu ao processo preso preventivamente - precedentes: HC 453.891/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 03/12/2018; RHC 82.759/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., DJe 06/06/2018; RHC 94.655/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 06/04/2018. No mesmo sentir, da Suprema Corte, o RHC 121528, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. em 03/06/2014.

3) Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no

momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal” - AgRg no RHC 116.112/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T. STJ, DJe 10/12/2019.

4) Não bastasse o sobredito posicionamento, com a prolação da presente sentença condenatória em cognição exauriente (após o exercício da ampla defesa e do contraditório), há inegável reconhecimento judicial da autoria e materialidade delitivas. De mais a mais, na esteira das decisões mencionadas adrede, a custódia cautelar é a única medida possível para garantia da ordem pública. Pontue-se também que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do sentenciado, na medida em que praticava o tráfico de drogas na Comarca de Tupã, espargindo droga de alto efeito deletério – bem como ostenta maus antecedentes e reincidência, a denotar a reiteração delitiva.

5) Acresça que, em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ, bem como pelas Súmulas 716 e 717 do Excelso Pretório. Assim, inexistindo prejuízos ao sentenciado quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019), não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos previstos na legislação de regência.

6) A negativa do direito em recorrer em liberdade no item adrede, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Em face da condenação supra, os réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11.608/2003.

Oportunamente, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, determino que se proceda ao seguinte:

- I) providencie-se o necessário à execução da pena imposta acima;
- II) oficie-se ao TRE/SP, para o cumprimento da regra estabelecida no inciso III, do art. 15, da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD;
- III) oficie-se ao Funad/Senad, a fim de serem observadas as providências cabíveis em relação ao decreto de perdimento de bens;
- IV) comunique-se a Autoridade Policial para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do art. 72 da Lei de Drogas.

P.R.I.C.

Tupã, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA